

1502114-10.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... condenações definitivas pelos crimes de tráfico (autos n.º 0002771-89.2015.8.26.0562 - certidão de p. 23), de furto simples tentado (autos n.º 0006695-45.2014.8.26.0562 - certidão de p. 24) e de furto qualificado (autos n.º 1500008-17.2018.8.26.0536 - certidão de p. 26).

Além disso, ostenta uma condenação definitiva antiga pelo crime de furto simples (autos n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTOS

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502114-10.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502114-10.2022.8.26.0536 - Controle n.º 516/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALBERTO FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA e DANIEL NASCIMENTO NERES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

ALBERTO FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA e DANIEL NASCIMENTO NERES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 14 de junho de 2022, por volta de 3h15min, no antigo prédio do Banco do Brasil, situado na Rua Dom Pedro II n.º 49, Centro, neste município e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, para proveito comum, subtraíram fios de telefonia e fios elétricos, que pesavam aproximadamente 30 (trinta) quilos, avaliados em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Diz a denúncia que os réus entraram no imóvel e retiraram os fios de telefonia e fios elétricos que lá se encontravam. Todavia, policiais militares foram avisados do delito e das características dos furtadores e, em diligências, localizaram os acusados na Rua Rubião Júnior, cada um carregando um saco volumoso, sacos esses que continham os bens subtraídos.

Por fim, diz a denúncia que, indagados sobre os fatos, ambos assumiram a prática

delitiva. Na ocasião, alegaram ser usuários de drogas (pp. 79/80). Recebida a denúncia (pp. 81/82), foram os réus citados pessoalmente (pp. 97 e 99). A Defesa ofereceu a resposta de p. 103, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 104/105). Na instrução foram ouvidas duas testemunhas, procedendo-se aos interrogatórios (pp. 166/167).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Ademais, sustentou a plena comprovação da qualificadora do concurso de agentes. Na dosimetria da pena, pretendeu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude dos maus antecedentes e da personalidade dos acusados, bem como o reconhecimento da reincidência de ambos. Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, pretendeu a imposição do regime fechado e a manutenção da prisão por sentença condenatória recorrível (pp. 214/218).

A Defesa, por sua vez, em seu memorial, requereu a absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretendeu a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da forma tentada do delito. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios legais, a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, postulou o acolhimento do instituto da detração na fixação do regime prisional (pp. 222/226). É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de avaliação (p. 2) e pelo auto de exibição e apreensão (p. 13).

A autoria dos fatos delituosos também é certa.

Perante a autoridade policial, e cientes da acusação que lhes era dirigida, os acusados mantiveram-se calados, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias que ensejaram suas prisões (pp. 10 e 11).

Em juízo, ao ser interrogado, o corréu Daniel informou que já foi processado e condenado por um assalto, cuja pena estava cumprindo em regime aberto. Conhecia o corréu Alberto apenas “de vista”. Recorda-se do policial Odnei. Negou a prática de qualquer crime. Contou que saiu para fazer reciclagem e, no caminho, encontrou fios de internet e cabos de rede, que não têm muito valor, e que estavam descartados em caçambas de entulho. Coletou esses objetos e os levava para vender no ferro-velho do Morro do São Bento, que funciona 24 horas. Disse que, em comparação com fios elétricos, esse tipo de fio tem baixo valor de revenda, portanto, muitas pessoas não o coletam. No caminho, avistou uma viatura parada e pensou que não teria problemas, pois não havia feito nada de errado, de modo que decidiu não mudar seu caminho e passar por ali. Quando se aproximou, o policial Odnei apontou a arma para ele e mandou encostar na parede onde já estava o corréu Alberto, dizendo que eles estavam juntos. Trazia apenas uma sacola de trinta litros, que estava leve, com cerca de oito quilos, e continha os fios, uma blusa e outros materiais velhos, como latinhas de alumínio. Não sabe que tipo de material havia na sacola do corréu Alberto. Não sabe onde encontraram as outras sacolas apresentadas na delegacia. Após ser abordado, os policiais colocaram-nos dentro da viatura e ficaram conversando do lado de fora. Afirmou que foi abordado por volta de 00h30min e não às 3h15min, como consta no boletim de ocorrência. No momento da abordagem ninguém disse nada sobre ter sido flagrado pelo sistema de monitoramento de câmeras da cidade. Disse que os policiais falaram que eles haviam roubado determinado lugar, sendo que nem havia passado por lá e nem esteve com o corréu Alberto. Passou por várias ruas da cidade, mas não se recorda se passou pela rua da agência do Banco do Brasil, uma vez que estava focado nas caçambas de lixo, de modo que não costuma prestar atenção nos nomes das ruas em que rua entra. Mora com seu primo em um apartamento no BNH. Tem 38 anos, ensino médio completo, é solteiro e não tem filhos. Era viciado em cocaína, mas fez um tratamento espiritual e não usa mais drogas há cinco meses. Exerce a profissão de açougueiro e estava buscando a documentação para reingressar no mercado de trabalho quando foi preso (pp. 183/194).

Em juízo, ao ser interrogado, o corréu Alberto disse que já foi preso, processado e condenado por outros crimes de furto. Estava cumprindo pena em regime aberto à época dos fatos. Só conhece o corréu Daniel “de vista”, pois ele também é morador de rua. Não conhece os policiais ouvidos, apenas se recorda deles em razão da abordagem. Contou que estava fazendo reciclagem e havia coletado latinhas e ferro, que pretendia vender em um ferro-velho que fica aberto de madrugada e assim pretendia comprar comida. No trajeto para esse ferro-velho foi abordado pelos policiais ouvidos na instrução e que afirmaram que ele estava com um saco de fios, sendo que ele não trazia fio nenhum. Estava sozinho no momento e não sabe o nome daquela rua, mas disse que se tratava da subida do Morro do Fontana. Disse que trazia uma sacola grande e volumosa por conta das latinhas que carregava, mas não havia nenhum fio nela. Relatou que o corréu Daniel foi abordado cerca de dez minutos após, um pouco mais para baixo, e que ele também trazia um saco de latinhas para vender no ferro-velho do morro. Afirmou que ele e o corréu Daniel não estavam juntos. Disse que os policiais apareceram com um saco de fios e diziam que o monitoramento os flagrou pegando aqueles fios na agência do Banco do Brasil. Diziam, ainda, que o saco com fios havia sido dispensado na rua pela qual eles transitavam. Não viu onde os policiais pegaram aquele saco, mas imagina que as pessoas que cometeram o furto dispensaram-no e os policiais acharam que se tratava de um deles. Disse que os sacos com fios eram grandes e pesados. Havia uma grande quantidade de fios, que os policiais falaram que iam dividir entre ele e o corréu Daniel, colocando um pouco para cada um, para assim incriminá-los. Imagina que os policiais tenham efetivamente acreditado que eles haviam furtado os fios e estavam ocultando os bens e dificultando o trabalho deles. Informou que os policiais chegaram com a sacola quando estavam puxando seus antecedentes e vendo que ele estava cumprindo pena em regime aberto. Mesmo tendo falado que o saco não era deles, o policial disse que acharam o saco no percurso que eles estavam fazendo e que eles eram suspeitos por terem sido vistos pela câmera de monitoramento. Disse que foram levados até a frente do Banco do Brasil, mas não chegaram a descer da viatura. Contou que queria dar depoimento na delegacia, mas o delegado disse que não seria preciso, pois iriam direto para a audiência de custódia e lá poderia se explicar. É morador de rua por causa de sua dependência química em crack. Tem família com residência no morro do Tetéu, na zona Noroeste de Santos. Tem 48 anos de idade e usa drogas há mais de vinte anos. Já tentou deixar o vício diversas vezes, mas não conseguiu. Desde que foi preso, não mais usou entorpecentes. Estudou até o sexto ano do ensino fundamental, mas por ser o mais velho de nove irmãos, parou de estudar para ajudar sua mãe. É solteiro e tem dois filhos, um com 22 e um com 16 anos de idade.

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

João Francisco de Oliveira Schimith, policial militar, narrou que o sistema de monitoramento do município de Santos informou sobre ocorrência de furto, pois visualizaram dois indivíduos saindo de uma agência desativada do Banco do Brasil, e carregavam sacos de plástico. O monitoramento passou as características dos indivíduos e relatou que um deles seguia no sentido do Morro São Bento, pela Rua Rubião Júnior, de modo que, ao irem naquela direção, encontraram o corréu Alberto com um saco contendo fios. Na mesma rua, o corréu Daniel vinha caminhando na direção da equipe policial com outro saco, que constatarem conter mais fios. Declarou que os acusados confessaram informalmente terem subtraído os bens da agência do Banco do Brasil. Disse que o prédio do Banco do Brasil não estava ocupado por nenhum estabelecimento. Está cercado por uma grade, mas, na parte superior, havia uma perfuração, pela qual passava uma pessoa. Ao serem abordados, os réus não declararam serem usuários de drogas. Não teve contato com os proprietários do imóvel para saber se algo foi subtraído do local. Reafirmou que os acusados não foram abordados juntos, mas, sim, a uma distância de meia quadra entre um e outro. Afirmou ter confirmado com o monitoramento que as pessoas abordadas eram as mesmas que foram vistas saindo daquele prédio. Também confirmou que os fios apreendidos haviam sido subtraídos do local. Não se recorda se viu as imagens do sistema de monitoramento. Ambos os réus traziam fios furtados em seus sacos, sendo

que um dos sacos continha fios azuis. Não houve perícia no Banco do Brasil. Não se recorda se o monitoramento disse que eles traziam mais de um saco cada um (pp. 168/175).

Odnei Almeida de Luca, policial militar, disse que foram acionados pelo monitoramento da cidade, pois dois indivíduos haviam sido identificados saindo do Banco do Brasil, na agência situada na Rua Dom Pedro II, e carregavam sacos plásticos. Foram informados de que os indivíduos seguiam pela Avenida São Francisco, sentido da Rua Rubião Júnior. Em um primeiro momento, depararam-se com o corréu Alberto na Rua Rubião Júnior, subindo o morro. Ao abordá-lo encontraram um saco plástico com fios. Posteriormente, o corréu Daniel apareceu pela mesma via, carregando mais fios, sendo também abordado. Afirmou que os acusados confessaram informalmente terem retirado os fios da agência desativada do Banco do Brasil. No momento da abordagem, o monitoramento confirmou a identidade dos réus. Analisando os fios apreendidos, não soube dizer se haviam sido retirados do mesmo local, mas afirmou serem fios azuis e cinzas. O sistema de monitoramento não informou quantos sacos os acusados traziam. Não recebeu as imagens das câmeras de monitoramento. Informou que o local contava com uma grade, mas havia um buraco nela e por esse buraco era possível entrar no imóvel. Não teve acesso à parte interna do imóvel. Relatou que outros furtos no local foram noticiados. Não acompanhou a perícia no local e não teve contato com o proprietário. Acredita terem sido apreendidos três sacos contendo fios, afirmando que um dos acusados trazia um saco e outro trazia dois, mas não sabe dizer qual dos réus trazia mais de um saco (pp. 176/182).

Vê-se, assim, que não se poderiam entender insuficientes as provas amealhadas, que se revelam coerentes, uníssonas e indicam a condenação.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares foram firmes, seguros e coerentes em seus relatos, não se evidenciando contradição capaz de retirar valor do contexto probatório.

Os policiais militares narraram que estavam em patrulhamento e receberam informação sobre dois indivíduos que foram observados pelas câmeras de monitoramento da cidade enquanto saíam levando sacos com material retirado da agência desativada do Banco do Brasil, situada na Rua Dom Pedro II.

Narraram que foi passada a descrição dos indivíduos e a direção que eles haviam seguido. Inicialmente, encontraram o corréu Alberto com um saco plástico contendo fios e, pouco depois, na mesma rua, abordaram o corréu Daniel, que trazia com ele um saco plástico que continha mais fios.

Disseram, ainda, que os réus confessaram informalmente o furto, sendo confirmada a identidade deles pelo monitoramento, que os apontou como sendo os indivíduos observados quando saíam da agência do Banco do Brasil.

Registre-se, ainda, que consoante entendimento predominante, a apreensão da res furtiva em poder dos agentes e logo após o fato gera presunção da responsabilidade deles na subtração, ocorrendo, assim, inversão do ônus da prova, competindo aos acusados trazerem elementos capazes de comprovar que não foram os autores do delito.

Sobre o ônus probatório, colhe-se da lição de Marcos Vinicius Boschi e outros que "conforme iterativa jurisprudência, a apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida. Vale dizer, o ordinário presume-se, o extraordinário é que deve ser provado. A apreensão da res furtiva em poder de alguém, mormente logo após o delito, conforme a experiência ordinária, diz por si mesmo, revelando-se altamente incriminadora. A situação, diz a jurisprudência, assemelha-se a do alibi invocado e não demonstrado, fazendo com que o réu seja havido como confesso, ou, pelo menos, corra o risco de sê-lo, dès que os demais dados probatórios transformem em certeza a presunção gerada pela justificativa dúbia ou inverossímil." (Código de Processo Penal comentado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 169-170).

E, como já se decidiu:

"... Roubo e Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a

inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem..." (TJSP; Apelação Criminal 1501570-42.2019.8.26.0628; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021).

Certo, pois, que a prova revelou que os acusados praticaram a conduta descrita na petição inicial e nada nos autos indica que os policiais militares pretendessem incriminar os réus indevidamente, como quiseram fazer crer.

Esses agentes públicos limitaram-se a narrar o ocorrido, não se tendo indicação alguma de que se trate de situação forjada para incriminá-los. Quiseram fazer crer que foram indevidamente acusados, mas essa afirmação cede à análise da prova aqui reunida.

Não há razão para desprezar a prova oral unicamente porque apenas policiais relataram detalhes a respeito da abordagem dos réus, localização e apreensão da res furtiva, encontrada em poder dos réus e não em via pública como sustentou a Defesa. Outrossim, quando coerentes as declarações dos policiais militares, como no caso aqui analisado, não se pode deixar de outorgar habitual valor probatório apenas em razão de sua condição de supostamente possuírem interesse em legitimar seus atos. Cabe à Defesa provar com segurança que tais depoimentos são viciados ou ostentam intenção de prejudicar os acusados.

Deste modo, tudo indica que os policiais agiram com lisura ímpar e, por certo, não se poderia desacreditar o relato de cada qual, uma vez que esses agentes procederam com a abordagem dos acusados e apreensão dos bens subtraídos, não se podendo entender como suspeitos aqueles que são investidos de poder para tal função.

Como já se decidiu:

"É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (HC 87662, Relator(a): Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007).

"... A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário..." (TJSP; Apelação Criminal 1500453-63.2018.8.26.0559; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2021).

De outro lado, sabe-se que os réus não estão obrigados a dizer a verdade: ao contrário, bem podem pretender alterar a verdade dos fatos, procurando afastar sua responsabilidade penal, justamente para não se prejudicarem.

Nestes termos, inaceitáveis as versões que os réus ofertaram, pois quiseram fazer crer que os policiais militares haviam encontrado sacos plásticos com fios e buscavam imputar injustamente sua posse a eles, sendo que o corréu Daniel apenas havia coletado alguns fios de internet em uma caçamba e o corréu Alberto não traria nenhum fio consigo.

Evidente que não há como admitir a fantasiosa versão, uma vez que a prova indica que os acusados foram abordados trazendo sacos que totalizavam mais de trinta quilos em fios de rede para internet e fios elétricos.

Assim, e como já se disse, do processado não se extrai razão plausível para que os policiais militares criassem diabólico plano visando incriminar os réus, pessoas que sequer conheciam, apontando-os como autores desse crime.

Seria inacreditável imaginar que agentes responsáveis pela segurança pública maquinassem fantasiosa história, forjando provas e o encontro de dezenas de quilos de bens subtraídos, para atribuir a dois inocentes um crime que não cometeram.

Despropositada, por absurda, essa situação.

Impossível, pois, dar credibilidade a versões tão dissociadas de todo o restante do contexto probatório.

Ressalte-se, por oportuno, que a abordagem dos réus não se deu ao acaso, mas, sim,

em razão de informação sobre suas características e destino que tomaram ao sair da agência bancária, dados esses fornecidos pela central de monitoramento após observação regular em situação de policiamento urbano.

A alegação de que haveria dúvida sobre serem os fios apreendidos pertencentes ao imóvel que abrigou a agência do Banco do Brasil também não prospera, pois os réus foram observados exatamente quando saíam do imóvel com os sacos plásticos, que foram com eles apreendidos.

Desta forma, patente está que não se tem fundamento que autorize a absolvição, uma vez que a prova aqui colhida bem indica que os réus subtraíram os bens descritos na denúncia.

Não se cogita de desclassificação para reconhecimento do crime tentado, como pretendido pela Defesa, e isso porque se considera consumado o delito quando o agente desloca ou remove a coisa, invertendo-lhe a posse, ainda que por breve período, sendo desnecessário, inclusive, que a posse seja tranquila, pacífica e desvigiada, segundo a teoria "amotio".

Neste sentido, é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Tema 934 - REsp nº 1524450).

Colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"... A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes..." (HC 135674, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, processo eletrônico, DJe-218 divulg 11-10-2016 public 13-10-2016).

Além disso, adotando esse entendimento, aponte-se julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"... Entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que o delito de furto se consuma com o simples apossamento do bem subtraído pelo agente, independentemente da circunstância de que essa posse não perdure no tempo, em face de perseguição e recuperação do objeto furtado em favor da vítima (Tema de recursos repetitivos número 934 do STJ) – Sentenciado que conduzia o veículo subtraído da vítima no momento da abordagem – Recurso defensivo desprovido – Recurso ministerial provido, com reflexo nas penas." (TJSP; Apelação Criminal 0020693-59.2017.8.26.0050; Rel. Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/02/2021).

Diga-se, ainda, que a qualificadora relativa ao concurso de pessoas é situação perfeitamente configurada, pois é de se reconhecer que os réus estavam efetivamente ajustados entre si e deram cabo à execução do crime de furto.

Inegável o auxílio e cooperação empreendidos pelos acusados, que agiram com unidade de propósitos e perpetraram a subtração dos bens localizados no interior do imóvel por eles invadido.

E, como já se decidiu:

"...O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas, pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa necessária ao êxito global da infração. Para a caracterização da coautoria no concurso de pessoas é necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, não se exigindo que todos os partícipes tenham consumado atos típicos de execução..." (TJSP; Apelação Criminal 1503167-16.2018.8.26.0229; Rel. Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 11/06/2020).

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, portanto, a ação penal.

Passo a individualização da pena.

Destaque-se que, não obstante não incidir no furto qualificado a causa de aumento de pena do repouso noturno, a situação de fato não pode ser desconsiderada pelo

juízo.

É certo que o furto ora analisado se deu em meio a alta madrugada – período em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminoso em razão da diminuição da vigilância exercida sobre a res – circunstância que é determinante no modus operandi dos criminosos e indicativa de inegável sucesso na atividade ilícita. Assim sendo, essa especificidade será considerada nas circunstâncias judiciais.

I – Alberto Francisco Ferreira de Souza

O acusado é reincidente, pois ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico (autos n.º 0002771-89.2015.8.26.0562 – certidão de p. 23), de furto simples tentado (autos n.º 0006695-45.2014.8.26.0562 – certidão de p. 24) e de furto qualificado (autos n.º 1500008-17.2018.8.26.0536 – certidão de p. 26).

Além disso, ostenta uma condenação definitiva antiga pelo crime de furto simples (autos n.º 0016128-83.2008.8.26.0562 – certidão de pp. 24/25), a qual, ainda que não sirva para configurar a agravante da reincidência, macula sua vida pregressa e deixa claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento em prática criminosa.

Note-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, se vê processado pelos crimes de furto qualificado tentado (autos n.º 1500236-84.2021.8.26.0536 – certidão de pp. 26/27; e autos n.º 1500565-96.2021.8.26.0536 – certidão de p. 27), de porte ilegal de drogas (autos n.º 1501312-02.2020.8.26.0562 – certidão de p. 27) e de furto simples e qualificado (autos n.º 1502885-22.2021.8.26.0536 – certidão de pp. 27/28), destacando-se que tais apontamentos não serão aqui considerados, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Na hipótese sub judice, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão dos maus antecedentes e circunstâncias desfavoráveis do crime, pois o furto foi praticado durante o repouso noturno, aumento a pena-base em 1/3 (um terço), fixando-a em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Comprovada a reincidência, representada por três condenações definitivas, sendo uma delas por tráfico, uma por furto qualificado e uma por furto simples tentado, o que não poderia ser desprezado, agravo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstâncias que a modifiquem.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reconhecida reincidência representada por três condenações definitivas, sendo uma delas por crime equiparado a hediondo e duas por crimes contra o patrimônio, e evidenciadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e maus antecedentes), iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como porque a substituição não seria recomendável e nem suficiente para reprovação de tal conduta delituosa.

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

II – Daniel Nascimento Neres

O acusado é reincidente, pois ostenta uma condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (autos n.º 1504106-11.2019.8.26.0536 – certidão de p. 30).

Na hipótese sub judice, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão das circunstâncias desfavoráveis do crime, pois o furto foi praticado durante o repouso noturno, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Comprovada a reincidência, representada por uma condenação definitiva por roubo majorado, o que não poderia ser desprezado, agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstâncias que a modifiquem.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reconhecida reincidência representada por uma condenação definitiva por crime contra o patrimônio, e evidenciadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime), iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como porque a substituição não seria recomendável e nem suficiente para reprovação da conduta delituosa.

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

Por fim, ressalte-se que inadmissível o reconhecimento da detração penal, prevista no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, aplicando-se regime prisional mais brando para o início de cumprimento da reprimenda para qualquer dos réus, como pleiteou a Defesa, uma vez que sequer se teria por preenchido pressuposto objetivo para a progressão do regime prisional.

Ademais, tal qual determina a Lei n.º 12.736/12, reconhece-se o direito à progressão para regime mais benéfico, desde que preenchidas as condições preceituadas nos artigos 113 e 114 da Lei n.º 7.210/84 (aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz; necessidade de estar trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente e apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime), tudo a ser comprovado perante o Juízo da Execução.

E, como já se decidiu:

"... Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP - Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença." (TJSP; Apelação Criminal 1501642-14.2018.8.26.0127; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/08/2020).

"... Deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para a avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime. Ademais, compete ao Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da Lei de Execuções Penais..." (TJSP; Apelação Criminal 0003472-88.2016.8.26.0635; Rel. Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2020).



Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) condenar ALBERTO FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 14 (catorze) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal; e,

b) condenar DANIEL NASCIMENTO NERES, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal;

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual n.º 11.608/03, arcarão os réus com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réus a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenham condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Os réus viram convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva e é certo que o fato aqui apurado desassossega a sociedade, compromete a paz social e desequilibra a ordem pública.

Assim, a prisão por sentença condenatória recorrível se revela necessária, seja para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como para resguardo da ordem e paz públicas.

Lembre-se que o corréu Alberto é reincidente, ostentando três condenações definitivas, sendo uma delas por crime hediondo e duas por crimes contra o patrimônio. O corréu Daniel é igualmente reincidente, ostentando uma condenação definitiva por violento crime contra o patrimônio.

Por final, necessário registrar que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para acautelar o procedimento, agora julgado nesta Instância, sendo forçoso reconhecer que, em liberdade, os acusados poderão pôr em risco a aplicação da lei penal, pois condenados a cumprir pena em gravoso regime, destacando-se que quando cometeram o crime aqui apurado ambos estavam cumprindo pena em regime aberto.

Desta forma, recomendem-se os réus Alberto Francisco Ferreira de Souza e Daniel Nascimento Neres na prisão em que se encontram.

Anotem-se as condenações definitivas no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento n.º 33/12 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 21 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA